

1514854-85.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Mas, em caso de condenação por tráfico, requereu concessão de benefícios previstos na Lei Penal, notadamente fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1514854-85.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514854-85.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WAGNER JOSE DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

WAGNER JOSE DOS SANTOS qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de junho de 2021, por volta das 12h30, na rua General Irulegui Cunha, no Parque São Lucas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, foi flagrado com 6,8 gramas de cocaína e 7,0 gramas de maconha (tetraidrocanabinol), que teria trazido consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo alheio.

Segundo consta na denúncia, observando às escondidas um ponto de venda de drogas, policiais civis viram o acusado andando de um lado para o outro. Por isso, abordaram-no. Então, encontraram com ele um estojo de óculos, que continha oito porções de cocaína, seis de maconha e R\$ 173,00 (cento e setenta e três reais). Interpelado, ele teria confessado que estava traficando.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em liberdade provisória (fls. 48/50). Todavia, tendo em vista que o réu descumpriu

as medidas impostas por ocasião da concessão da liberdade, deixando de comparecer em juízo para justificar mudança de endereço, colocando-se inacessível ao juízo com o que impede a aplicação da lei penal, sua liberdade provisória foi revogada (decisão de fls. 85/86), sendo preso preventivamente (fls. 91/93).

A denúncia foi oferecida às fls. 74/76.

A decisão de fls. 77 determinou a citação e notificação do acusado.

O réu foi citado (fls. 128) e apresentou defesa prévia por meio da Defensoria Pública (fls 133).

Recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução, debates e julgamento para 14 de fevereiro de 2.022 (fls. 134).

Durante a instrução, tomou-se o depoimento da testemunha Leandro Villela P.

Moretti, redesignando-se audiência para oitiva da testemunha Valmir Alves

Francisco, que estava de férias. Na nova data designada, recebeu-se notícia acerca da transferência do acusado, sendo necessária a redesignação da audiência. Tendo em vista o prazo que já se encontrava preso provisoriamente, o benefício da liberdade provisória foi restabelecido.

Na nova data designada, ouviu-se a testemunha faltante Valmir Alves Francisco, interrogando-se o réu ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, concordou com aplicação do redutor legal, frente à falta de antecedentes criminais pelo réu.

Já, a Defesa requereu, com fundamento no princípio constitucional da ampla defesa e da presunção de inocência, a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, em caso de condenação, requereu desclassificação para o artigo 28, da Lei de Entorpecentes.

Mas, em caso de condenação por tráfico, requereu concessão de benefícios previstos na Lei Penal, notadamente fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição (fls. 13), laudo de constatação (fls. 34/36), laudo pericial definitivo (fls. 115/117), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas negativas durante interrogatório judicial.

Vejamos.

O réu, na fase policial (fls. 05), exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ouvido em Juízo, afirmou ser divorciado, ter três filhos, ter cursado o 1º Grau

Completo, estar desempregado, ser viciado em cocaína, "crack", "maconha" e álcool.

Nega os fatos narrados na denúncia. Disse que as drogas que estavam em seu poder

eram para seu uso próprio e não para venda à terceiros. Afirmou que estava com

aproximadamente R\$200,00 (duzentos reais) para gastar com drogas também. Ressaltou

que, à época dos fatos estava em situação de risco, morando na rua e trabalhando

com reciclagem para sustentar seu vício, bem como, ser viciado no uso de

entorpecentes há mais de trinta e cinco anos. Afirmou que seis porções de "maconha"

e sete porções de cocaína eram consumidas em, no máximo, dez horas. Há dois meses,

porém, após sair da prisão, está realizando tratamento junto ao CAPS para se livrar do vício.

A negativa apresentada pelo acusado, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

A testemunha VALMIR ALVES FRANCISCO, policial civil, em fase policial (fls. 07), relatou que, na data dos fatos: foi deflagrada operação denominada "NARCOS BRASIL", objetivando combater o tráfico de drogas na zona leste da capital. Sabedores da existência de um local, conhecido pela comercialização de drogas próxima a esta delegacia de polícia, diligenciaram com uma viatura descaracterizada pelas imediações, onde após realizarem uma breve "campana", observaram um indivíduo em atitude suspeita, andando de um lado para o outro na via pública. Por essa razão, efetuaram a abordagem do indivíduo, que inicialmente apresentou justificativas diversas para o que estava fazendo parado naquele local, demonstrando grande nervosismo. Em revista pessoal, localizaram em seu poder uma caixinha de óculos, contendo 08 papelotes de cocaína e 06 papelotes de maconha, além da importância de R\$ 173,00 em espécie, representado por diversas cédulas de vários valores. Ato contínuo, questionaram o indivíduo, que foi identificado posteriormente como sendo Wagner José dos Santos, acerca dos entorpecentes, tendo ele confirmado estar comercializando drogas no local há tempos, informando ainda que o dinheiro localizado em seu poder seria fruto desta comercialização. O indivíduo também informou que já teria sido preso por tráfico tempos atrás. Por esta razão, deram voz de prisão ao indivíduo, conduzindo-o a esta Unidade Policial para devidas providências de Polícia Judiciária, algemando-o.

A testemunha LEANDRO VILLELA PELLEGGATTI MORETTI, também policial civil, em fase policial (fls. 08), apresentou idêntico relato ao de seu colega.

O policial LEANDRO, ouvido em audiência, confirmou a ocorrência descrita na denúncia, afirmando que trabalhava numa operação policial contra o tráfico de entorpecentes na Zona Leste. Foi até o local indicado na denúncia, que é um ponto conhecido de tráfico de entorpecentes pela Polícia, com uma viatura descaracterizada. Lá chegando, se deparou com o réu que estava muito nervoso e, andava de um lado para o outro. Em revista pessoal, foram encontradas as drogas descritas na denúncia, além de certa quantia em dinheiro (entre R\$150,00 à R\$200,00). De maneira informal, o réu admitiu o tráfico de entorpecentes no local inclusive, informando que neste mesmo local, já havia sido preso anteriormente. Por sua vez, em Juízo, o policial VALMIR, ouvido em audiência, afirmou que no ano passado participou da operação NARCOS BRASIL, de combate ao tráfico de entorpecentes. O local mencionado na denúncia, já era conhecido da Polícia, como de intenso tráfico de drogas e, foram para lá, com uma viatura caracterizada, analisaram a conduta do réu que era suspeita, haja vista ficar andando de um lado para outro, aparentando certo nervosismo. Diante disso, retornaram ao Distrito Policial, trocaram de carro (viatura descaracterizada) e, novamente foram para o ponto de venda de drogas. Após campana de aproximadamente trinta minutos, realizaram a prisão do réu. O réu aparentava ser um senhor de mais idade e, trazia consigo, nas mãos, uma caixinha de óculos, com os entorpecentes em seu interior. Diante do lapso temporal já decorrido, não se recorda qual a versão apresentada pelo réu no momento de sua prisão.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, funcionários públicos, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídos somente de

interesse no esclarecimento da verdade.

Frise-se que a versão apresentada pelo acusado paira, de forma isolada, no conjunto probatório dos autos, mesmo porque, não é crível, que pessoa em situação de rua, que vivia de reciclagem de materiais pudesse adquirir entorpecentes diariamente, consumir mais de dez porções e, ainda, manter quase R\$200,00 (duzentos reais) em seu poder. É de se observar que as condutas não são excludentes, ou seja, um viciado pode traficar entorpecentes e, vice-versa.

O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar da negativa do acusado, durante seu interrogatório judicial, pela quantidade e diversidade da droga apreendida, consistente em um montante de 7 gramas, no qual foi detectado a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), além de um montante consistente 6,8 gramas, no qual foi detectado a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), bem como pela quantia em dinheiro, no total de R\$ 173,00 (cento e setenta e três reais) em cédulas de pequeno valor, corroborado pela narrativa dos policiais que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Destaque-se, por oportuno, que a quantidade e a diversidade da droga apreendida não se presta ao reconhecimento do porte para uso próprio, visto que não se trata, em hipótese alguma, consoante ressaltado, de quantidade irrisória.

A quantidade, a variedade e o modo de disposição das drogas (embaladas individualizadas) e as circunstâncias em que apreendidas, em ponto conhecido como sendo de tráfico de drogas, mostram-se compatíveis com destinação para o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido.

Isto em conjunto com as demais provas amealhadas em regular instrução em juízo, denotam a incidência da conduta tipificada no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Quanto à tese defensiva de que o réu faria jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, verifica-se que, de fato, é réu é primário, não possui maus antecedentes como se observa da folha de antecedentes (fls. 37/38) e certidão de (fls. 39/40).

Não há indícios, nos autos, de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Em que pese a certidão de fls. 39 indicar a existência de ação penal em andamento, relativa ao crime de tráfico de drogas, considerando-se que não há sentença transitada em julgado, não há de ser valorada. Desta forma, a fração de diminuição da pena incide em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Destaco, por fim que, para não incorrer em bis in idem, as circunstâncias da quantidade e natureza da droga não serão utilizadas na primeira fase da dosimetria, já que foram consideradas para fixação de patamar menos elevado da causa de diminuição de pena (STF. Plenário. ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014 -repercussão geral).

O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar das negativas do acusado, corroborada pela narrativa coesa policiais que participaram de sua prisão, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, verifica-se que nenhuma das circunstâncias elencadas têm o condão de agravar a pena base do réu. Embora haja inquérito e ação penal em andamento, não há que se valorar em observância à súmula 444 do STJ, segundo a qual "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, afastada a agravante suscitada pelo Ministério Público, como já destacado anteriormente. Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda além do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça).

Desta forma, fica mantida a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, tem-se que a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º, do art. 33, incide em grau máximo, de 1/3 (um terço), como já salientado na fundamentação. Vão as penas, pois, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

O regime inicial de cumprimento de pena será ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c" do Código Penal.

Não se aplica o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, já que fixado regime mais favorável.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução número 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP).

A suspensão condicional da pena, contudo, passível de revogação com obrigação de integral cumprimento da pena corporal é admissível, acenando com mais relevante consequência, melhor atendendo ao reclamo de proporcionalidade da pena.

Determino, pois, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos, ao longo do qual obrigado o condenado a comparecer mensalmente perante o Juízo de Execução para informar e justificar suas atividades, ficando proibido de mudar de endereço e de se ausentar da comarca de residência sem prévia autorização judicial; no primeiro ano do período de prova, o réu está obrigado a prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, tal como dispuser o Juízo de execução.

À minguia de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu WAGNER JOSE DOS SANTOS, por infração ao artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Suspendo a execução da pena de reclusão pelo prazo de 2 (dois) anos, ao longo do qual obrigado o réu a comparecer mensalmente perante o Juízo de execução para informar e justificar suas atividades e proibido de mudar de endereço e de se ausentar da Comarca de residência sem prévia autorização judicial; no primeiro ano do período de prova, o réu está obrigado a prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, tal como dispuser o Juízo de execução.

Acusado encontra-se em liberdade provisória, cumprindo as condições impostas.

Assim, faculto recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) não reclamada a restituição do aparelho celular/objetos apreendido a fls. 13, em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua

destruição; d) oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova (artigo 72, da Lei 11.343/06); e) oficie-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III da CF/88, f) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil; g) decretada a perda do valor apreendido (R\$ 173,00) em favor da União, transfira-se ao Funad. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 22 de agosto de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA